

第 67 問

甲は、就職活動をしていたが、甲が高卒であったことが大きく影響して、就職先を見付けることができずにいた。そこで、甲は、一流大学である A 私立大学を卒業した友人の B から、卒業証書を借り受け、自分が A 大学を卒業したように見せかけようと考えた。当該卒業証書は、「卒業証書」との題名が付されており、卒業者氏名として「B」と記載され、その下に、「上記の者が、A 大学を卒業したことを証する。A 大学学長 C」と記載されている。甲は、卒業者氏名として「B」と記載されている部分に、あらかじめ用意していた「甲」と記載されている紙をそっと置いてメンディングテープで固定した（以下、このようにして作成した書面を「本件書面」という。）。甲は、本件書面を複写機で複写することにより、A 大学学長 C が作成した「甲」が A 大学を卒業したことを証する書面の写しであるかのような外観を有する写真コピーを作成し、これを甲が入社を希望する会社にした。

また、甲はファミリーレストラン D のアルバイトの応募に当たっても本件書面を利用しようと思い立ち、これをスキャナーで読み取らせた上で P D F データを作成し、D にメールで送付した。

以上の事例における甲の罪責について論ぜよ。

第1 前段の行為について

いわゆる写真コピーと偽造の問題である（**論点** 写真コピーと偽造  旧H12-2）。この点について、判例（最判昭51.4.30【百選Ⅱ88】）は「公文書偽造罪は、公文書に対する公共的信用を保護法益とし、公文書が証明手段としてもつ社会的機能を保護し、社会生活の安定を図ろうとするものであるから、公文書偽造罪の客体となる文書は、これを原本たる公文書そのものに限る根拠はなく、たとえ原本の写であっても、原本と同一の意識内容を保有し、証明文書としてこれと同様の社会的機能と信用性を有するものと認められる限り、これに含まれるものと解するのが相当である」。写真コピーは、「写ではあるが、複写した者の意識が介在する余地のない、機械的に正確な複写版であって、紙質等の点を除けば、その内容のみならず筆跡、形状にいたるまで、原本と全く同じく正確に再現されているという外観をもち、また、一般にそのようなものとして信頼されうような性質のもの、換言すれば、これを見る者をして、同一内容の原本の存在を信用させるだけではなく、印章、署名を含む原本の内容についてまで、原本そのものに接した場合と同様に認識させる特質をもち、その作成者の意識内容でなく、原本作成者の意識内容が直接伝達保有されている文書とみうようなものであるから、このような写真コピーは、そこに複写されている原本が右コピーどおりの内容、形状において存在していることにつき極めて強力な証明力をもちうるのであり、それゆえに、公文書の写真コピーが実生活上原本に代わるべき証明文書として一般に通用し、原本と同程度の社会的機能と信用性を有するものとされている場合が多いのである。右のような公文書の写真コピーの性質とその社会的機能に照らすときは、右コピーは、文書本来の性質上写真コピーが原本と同様の機能と信用性を有しえない場合を除き、公文書偽造罪の客体たりうるものであって、この場合においては、原本と同一の意識内容を保有する原本作成名義人作成名義の公文書と解すべきであり、また、右作成名義人の印章、署名の有無についても、写真コピーの上に印章、署名が複写されている以上、これを写真コピーの保有する意識内容の場合と別異に解する理由はないから、原本作成名義人の印章、署名のある文書として公文書偽造罪の客体たりうるものと認めるのが相当である」（下線部は担当者）と述べ、これを肯定的に解している。

その後、最決昭54.5.30、最決昭58.2.25、最決昭61.6.27が同様の判断を行っている。

なお、同判決は公文書偽造罪に関するものであるが、私文書偽造罪についても、同様に解することができると評されている（東京地判昭55.7.24）。

判例の立場に立つ限り、有印私文書偽造罪（159Ⅰ）が成立する。また、写真コピーを甲が入社を希望する会社にした点について、同行使罪が成立する（161Ⅰ）。

第2 後段の行為について

- 1(1) 問題となるのは、本件書面を作成した行為について偽造となるのか否かである。この点については、偽造の程度の問題である（**論点** 偽

造の程度 (旧H15-2)。

偽造の程度については、「一般人をして真正な文書であると誤信させる程度」である必要がある(大判大元.10.31)が、問題は行使の態様まで考慮要素として取り入れることができるか否かである。

- (2) この点について、大阪地判平8.7.8【百選Ⅱ90】は肯定的に解するものの、東京高判平20.7.18は否定的に解しており、下級審レベルで結論が分かれている。なお、東京高判は、健康保険証のコピーに他の保険証のコピーから切り貼りをして作成した保険証様の書面をファックスで送信し相手方の端末画面に表示させた事案について、同書面を原本の偽造とすることを否定し、保険証の写しを偽造しその写しを送信し行使したとした。本問でこのような考え方によった場合には、後段では、コピーの作成がなされていない(電子データだけである)以上、文書偽造罪は成立しないことになる。

また、本問では、本件書面を作成した時点においては、後段の行為が予定されていなかったものであり、前段については、写真コピーの偽造を問題とすれば足りるから、上記の点について肯定説に立ったとしても、偽造の成立を否定するという見解もありうるだろう。

- 2 本件書面を作成した行為が偽造に当たらないとした場合には、PDFデータが電磁的記録であることから、電磁的記録不正作出罪(161の2 I)を成立させて処理することになる。

答案構成

第1 本件書面を作成した行為

1 有印私文書偽造罪（159 I）の成否

↓

「偽造」の程度

↓

一般人をして真正に作成された文書であると誤認させるに足りる程度が必要である

↓

「偽造」否定

↓

2 少なくともこの段階では、上記行為について有印私文書偽造罪は成立しない

第2 本件書面を複写し、写真コピー（「以下「本件コピー」という。」）を作成した行為

1 「事実証明に関する文書」

↓

あてはめ

↓

2 「文書」

↓

写しであっても原本と同一の意識内容を保有し、証明文書としてこれと同様の社会的機能と信用性を有すると認められる限り「文書」に含まれる

↓

あてはめ

↓

「偽造」

↓

「偽造」とは、作成者と名義人との間に不一致を生じさせることである

↓

あてはめ

↓

「偽造」に当たる

↓

「他人の印章若しくは署名」が複写されていれば、有印といえる

↓

あてはめ

↓

3 「行使の目的」

↓

有印私文書偽造罪成立

↓

同行使罪（161 I）も成立し、牽連犯となる

第3 本件書面をスキャナーで読み取らせた上でPDFデータを作成した行為

- 1 甲が本件書面を改ざんしたというだけでは、有印私文書偽造罪は成立しないし、甲がスキャナーで虚偽のPDFデータを作り出した行為についても、電磁的記録不正作出罪（161の2 I）が成立するにとどまるようにも思われる

↓

一般人をして真正に作成された文書であると誤認させるに足りる程度に達しているか否かは、文書の行使態様等も考慮することができる

↓

あてはめ

↓

- 2 有印私文書偽造罪及び同行使罪が成立し、牽連犯となる

↓

- 3 第2の罪と併せて全体が一罪となる

第1 本件書面を作成した行為

1 上記行為につき、有印私文書偽造罪（159条1項）の成立が考えられる。なお、卒業証書の氏名欄はその本質的部分であるから、変造罪（同条2項）ではなく、偽造罪の成否を検討すべきである。

この点について、「偽造」といえるためには、一般人をして真正に作成された文書であると誤認させるに足りる程度に至っていることが必要である。

本問では、甲は「B」と記載された卒業証書の卒業者氏名欄に「甲」と記載された紙を置いてメンディングテープで固定しただけであり、客観的にみて、改ざんされたものであることが明らかである。

2 よって、上記程度には至っておらず、「偽造」とは言えないから、少なくとも、この段階では上記行為に有印私文書偽造罪は成立しない。

第2 本件書面を複写し、写真コピー（「以下「本件コピー」という。）を作成した行為

1 上記行為について、有印私文書偽造罪の成立が考えられる。

「事実証明に関する文書」とは、実社会生活に交渉を有する事実を証明するに足りる文書を意味するところ、A私立大学の卒業証書は、A私立大学の全課程を終え、同大学を修了した事実を証明するに足りる文書であるから、これに当たる。

2(1) もっとも、原則として「文書」として保護に値するのは、原本に限られる。そうだとすれば、本件コピーのような写真コピーは「文書」には当たらないのではないか。

1

この点について、「文書」が原本に限られるのが原則とされるのは、通常写しが原本と同様の社会的機能や信用性を有しないからである。そうだとすれば、たとえ写しであっても原本と同一の意識内容を保有し、証明文書としてこれと同様の社会的機能と信用性を有すると認められる限り、「文書」に含まれると解すべきである。

本件コピーは、その複写の正確性から、原本たるA大学の卒業証書と同一の意識内容を保有しており、また、証明文書としてこれと同様の社会的機能と信用性を有すると認められる。

したがって、「文書」に当たる。

(2) 次に、上記「文書」を「偽造」したといえるか、検討する。

「偽造」とは、作成者と名義人との間に不一致を生じさせることである。では、本件コピーの名義人は誰か。

文書偽造罪の保護法益は、文書に対する一般人の信用である。そうだとすれば、名義人は、文書を受け取った一般人において、当該文書の記載内容、形式、性質等から、誰の意思・観念が記載されている文書であると認識するのかという観点から判断されるべきである。

写真コピーはその性質上、これを見る者をして印章・署名までを含めた原本の内容について、原本に接した場合と同様の認識をさせるものであるから、作成名義人は原本作成名義人であると解する。

したがって、本件コピーの名義人はA大学学長Cである。一方で、作成者は甲であり、作成者と名義人との間に不一致が生じている。

よって、「偽造」といえる。

2

(3) そして、「他人の印章若しくは署名」が複写されていれば、これを写真コピーの保有する意識内容の場合と別異に解する理由はないから、有印であるといえる。

本問では、本件コピーには「A大学学長C」の「署名」が複写されているから、有印である。

3 甲には、「行使の目的」も認められるから、上記行為について、有印私文書偽造罪が成立する。

また、本件コピーを甲が入社を希望する会社へ送った行為については、偽造文書を認識させ又はこれを認識し得る状態においているから、これを「行使」したものとして、同行使罪（161条1項）が成立する。

4 両罪は、目的手段の関係にあるから、牽連犯（54条1項後段）となる。

第3 本件書面をスキャナーで読み取らせた上でPDFデータを作成した行為

1 (1) 上記のように、甲が本件書面を作成したというだけでは、有印私文書偽造罪は成立しないし、甲がスキャナーで虚偽のPDFデータを作り出した行為についても、電磁的記録不正作出罪（161条の2第1項）が成立するにとどまるように思える。

(2) もっとも、本件書面をスキャナーで読み取らせ、PDFデータを作成するという行使態様まで含めて「偽造」ということはできないか。

上記のように、「偽造」といえるためには、一般人をして真正に作

3

成された文書であると誤認させるに足りる程度である必要があるが、その程度に至っているか否かは、当該文書の客観的形狀だけでなく、当該文書の種類・性質や社会における機能、そこから想定される文書の行使の形態等をも併せて考慮することができると解する。

本問では、卒業証書の原本を直接見れば氏名の欄が改ざんされていることは明白であるが、スキャナーで読み取らせてPDFデータにすることによって、改ざんの有無が判断できないようになっている。そうだとすれば、本件書面の作成からスキャナーで読み取らせてPDFデータを作成するまでの一連の行為は、一般人をして真正に作成された文書であると誤認させるおそれを創出しているといえる。

したがって、上記行為は「偽造」に当たる。

2 その他の要件については、第2で検討したところと同様であるから、上記行為について甲に有印私文書偽造罪が成立する。

また、甲はDにこのPDFデータを送付し、偽造文書を認識させ又はこれを認識し得る状態においているから、同行使罪も成立する（161条1項）。これら二罪も第2で検討したところと同様に、牽連犯の関係となる（54条1項後段）。

3 そして、上記二罪と第2で検討した二罪は、実体としてみれば1つの文書に対する社会的信頼を害するものである。そうだとすれば、これらは包括して評価すべきである。

したがって、第2で検討した二罪も含め、全体として一罪が成立することになる。

以上

4